

1500351-92.2022.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... quanto ao crime de associação para o tráfico em razão da ausência dos elementos caracterizadores do delito. Acerca do tráfico de drogas, pugnou pela improcedência por ausência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegada nulidade da prisão dos réus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500351-92.2022.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-92.2022.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110107/2022 - DEL.POL.IBIÚNA, 24483905 - DEL.POL.IBIÚNA, 2110107 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ANTONIO HENRIQUE GOES GUIMARÃES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CARLOS HENRIQUE DO CARMO e ANTONIO HENRIQUE GOES GUIMARÃES, devidamente qualificados na denúncia, dados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, em data anterior a 24 de abril de 2022 até esta, em local incerto, associaram-se para o fim de praticar, de forma permanente e estável, o crime de tráfico de drogas. Consta ainda que, no dia 24 de abril de 2022, por volta das 21h30min., na Rua do Porto, próximo Cachoeira do Bosó, Gemina, nesta cidade e comarca de Ibiúna, CARLOS HENRIQUE DO CARMO e ANTONIO HENRIQUE GOES GUIMARÃES, agindo em concurso de agentes,

com ajuste prévio e cooperação recíproca, adquiriram e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções de cocaína, na forma de pó, pesando aproximadamente 4,2g, e 19 (dezenove) porções de cocaína, na forma de "crack", pesando aproximadamente 3,6g.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 02/04). Auto de exibição e apreensão (fls. 27/28). Termo de audiência de custódia (fls. 53/55). Laudo pericial (fls. 147/150).

Notificados (fls. 185 e 187), os réus ofereceram defesa prévia (fls. 121/136).

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 173/175).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada por videoconferência, foram ouvidas testemunhas e após, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela parcial procedência da ação penal, condenando-se os réus pela infração ao disposto no artigo 33 da Lei de Drogas. Já a Defesa dos acusados, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante realizada por guardas municipais. No mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico em razão da ausência dos elementos caracterizadores do delito. Acerca do tráfico de drogas, pugnou pela improcedência por ausência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegada nulidade da prisão dos réus efetuada por guardas civis municipais.

Isso porque, a uma, conforme determina o artigo 301, do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O Guarda Municipal está incluído neste rol e não há qualquer indicação de desvio de função como agentes públicos, tendo em vista que apresentaram a ocorrência à Autoridade Policial para os devidos trâmites legais. Ainda, mesmo que não tivessem agido os guardas como agentes públicos, considerando que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, com sua consumação protraída no tempo, qualquer pessoa estaria autorizada a prender em flagrante os acusados, não sendo necessária autorização judicial ou conduta policial para tanto.

A duas porque estavam presentes no momento da abordagem as fundadas razões necessárias para sua autorização, uma vez que o investigado Carlos estava em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, no período da noite, agachado em local ermo e escuro. Logo, diante destes elementos, por óbvio, estava em atitude suspeita, autorizadora de sua abordagem para verificação. Consigno que guardas municipais devem zelar não só pelo patrimônio público, mas também pela segurança social, ainda que tal atribuição não esteja inserida dentre as previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal.

Nesse sentido: "É firme a jurisprudência no sentido de que a Guarda Municipal, a teor do disposto no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito. A legalidade da abordagem e diligências realizadas pelos guardas municipais é assegurada pela Lei nº 13.022/14, que atribuiu aos guardas municipais o patrulhamento preventivo, bem como o dever de encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração" (STJ - HC: 776204 SP 2022/0319500-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 21/10/2022)

Por fim, assim tem decidido o C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso

concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. 6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 ?, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 29/09/2021). Grifei.

No mérito, a pretensão acusatória deve ser julgada procedente, mas em parte. A materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas se encontra bem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo termo de audiência de custódia (fls. 53/55), pelo laudo pericial (fls. 147/150), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados. Vejamos.

O guarda civil municipal Tomaz Edson Araujo de Oliveira narrou que estavam em patrulhamento quando viram Carlos agachado próximo à guia e de início, acharam até que ele poderia estar passando mal. Aproximaram-se e pararam para ver o que estava acontecendo, momento em que notaram que Carlos mexia em uma moita. O investigado Carlos estava com uma sacola nas mãos e no interior desta havia drogas. Relatou que durante a abordagem de Carlos, chegou Antônio dizendo que estavam juntos, vendendo drogas. Alegou que não tinham avistado Antônio e ele se apresentou espontaneamente. Não se recorda se foi dada voz de prisão a Carlos. Respondeu que a princípio acharam que Carlos estava passando mal porque ele estava sentado, arcado e sozinho no local. Aduziu que é normal pararem para verificar quando visualizam algum cidadão possivelmente passando mal. Declarou que o local da prisão é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

Vinicius Augusto Saturnino, guarda civil municipal, apresentou a mesma versão de seu colega Tomaz. Relatou que encontraram Carlos abaixado próximo a uma guia da sarjeta e com uma sacola nas mãos. Ao ser abordado, de pronto Carlos confessou a traficância. Logo em seguida, Antônio, espontaneamente, se aproximou e declarou que estava junto a Carlos, auxiliando-o na venda de drogas. Afirmou que a guarnição se surpreendeu com a atitude de Antônio, uma vez que nem tinham o avistado pelo local, e quando ele se aproximou, logo disse que não deixaria o amigo ir preso sozinho, porque estava como "olheiro" para ele e por isso estavam juntos. Alegou que o local

da prisão é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Afirmou que Carlos estava em atitude suspeita, tendo em vista que estava agachado em uma moita em lugar ermo e escuro. Ainda, pensaram que talvez ele pudesse estar passando mal, mas quando o abordaram, ele já levantou com a sacola em mãos e confessou a venda de drogas. Declarou que no momento da abordagem, disse ao réu Carlos sobre os direitos dele, inclusive o de permanecer em silêncio. Declarou que conhecia o réu Antônio porque ele já foi apreendido pela guarda municipal, mas não se recorda se ele foi preso. Quanto a Carlos, o conhecia porque já havia o abordado antes, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Interrogado, o réu Antônio negou a prática delitativa. Alegou que somente veio a conhecer Carlos quando já estavam presos. Relatou que o local da prisão é perto de sua casa. Na mesma data, pela manhã, em frente sua casa e na companhia de sua mãe, foi abordado pelo guarda municipal Vinicius, que o questionou sobre estar traficando, oportunidade em que negou. Já no período da noite, estavam num bar próximo quando avistou o giroflex da viatura da guarda e se aproximou para ver o que estava acontecendo, ocasião em que foi algemado pelos guardas, os quais disseram que estava associado a Carlos para o tráfico. Nesta oportunidade, o réu Carlos negou que o conhecesse. Não chegou a ver Carlos ser abordado, pois quando se aproximou, ele já estava algemado. Aduziu que já foi preso por ser usuário de drogas. Declarou que o guarda Vinicius o abordava sempre. Quanto à versão dada em sede policial, disse que apenas lhe foi dado um papel e assinou sem ler. Afirmou que sua mãe estava presente na delegacia, quando se negou a dar seu depoimento. Em audiência de custódia, Antônio disse que estava trabalhando com o pai como vendedor ambulante. Afirmou que Carlos é seu amigo. Contou que estava num bar quando Carlos chegou e iria apresentar uma menina a ele. Estava andando atrás de Carlos quando a polícia o algemou. Carlos já estava algemado. Deu depoimento na delegacia, mas não confirma tudo que está escrito no depoimento porque não estava associado com Carlos. Sofreu pressão psicológica por parte dos guardas que diziam que ele iria ficar preso por tráfico. Não foi ameaçado.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Carlos negou os fatos imputados a si. Relatou que mora do outro lado da cidade e estava no local da prisão para encontrar uma menina. Já era o segundo encontro com essa menina. Declarou que não estava agachado. Narrou que passou pela casa da menina e continuou andando para o ponto de encontro deles. Dado momento, estava andando, quando um guarda saiu do meio do mato e o segurou, dizendo: "perdeu, perdeu". De pronto, o guarda já o algemou e jogou no chão. Logo, o guarda apareceu com uma sacola e então chegaram viaturas, que estavam escondidas. Contou que a menina que ficaria, compareceu ao local e disse que era sua namorada e que iriam se encontrar, mas os guardas a ignoraram. O guarda que o abordou foi Marcos, que já havia verbalizado que o queria preso novamente. Na época, trabalhava todos os dias e estava casado, mas havia brigado com a esposa e por isso foi encontrar a menina. Afirmou que o valor de R\$ 40,00 era seu, mas não tinha nenhuma droga em seu poder. Não sabia que aquela rua era ponto de drogas. Já foi condenado por tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, Carlos afirmou que estava há um mês desempregado, mas estava procurando serviço. Narrou que passou pela cerca, abaixou e então o policial já o pegou. Estava acompanhado de Antônio, que tentou fugir, mas os guardas lhe deram uma rasteira. Declarou que nem chegou a pegar na droga, que passou pela cerca e estava em cima da droga já, mas os policiais estavam esperando. Logo, os guardas chegaram com Antônio. Afirmou que estava na companhia de Antônio e, sua namorada e uma amiga dela estavam atrás, uma vez que a amiga iria ficar com Antônio. Foi abordado pelo guarda municipal Marcos, mas não tem nada contra ele, inclusive havia sido abordado já por ele.

Pois bem.

Após dilação probatória, diante das provas colhidas, não restam dúvidas de que os réus praticaram, juntos, o tráfico de drogas, na data dos fatos mencionados nestes autos.

As palavras dos guardas municipais, que apreenderam o entorpecente com o acusado Carlos, bem como ouviram a confissão do réu Antônio, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de

sua credibilidade.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos agentes estatais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372). No mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349.

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a validade probatória ordinária.

Ademais, não há qualquer prova a evidenciar que os guardas municipais mentiram em juízo para prejudicar os réus. Pelo contrário, há, em verdade, muitos elementos a indicar que são os acusados que apresentaram versões totalmente dissonantes entre si e entre seus próprios depoimentos, prestados durante a audiência de custódia e a instrução do feito.

Vejamos todas as incongruências dos depoimentos dos autuados.

A começar, em seu interrogatório judicial, o réu Antônio foi categórico ao afirmar que não conhecia Carlos antes da prisão. Todavia, perante este mesmo Juízo, em audiência de custódia, declarou espontaneamente que Carlos é seu amigo e naquela data, iria apresentar a ele uma amiga. A versão de que os acusados são amigos ampara o relatado pelos policiais, de que Antônio se apresentou espontaneamente, dizendo que não deixaria o amigo ser preso sozinho.

Ainda, Antônio declarou que na data de sua prisão, havia sido abordado pela guarda municipal na parte da manhã, quando estava na companhia de sua mãe. Porém, sequer arrolou a própria mãe para confirmar sua versão. Todavia, mesmo que se considere como verdadeira tal narrativa, mostra-se extremamente sem coerência que uma pessoa abordada pela manhã, tenha, no período da noite, após avistar sinal de "giroflex", ido de encontro à guarda municipal apenas por curiosidade. Tal versão não se sustenta, eis que o próprio acusado Antônio alegou que o guarda Vinicius sempre o abordava, inclusive havia feito isso naquela manhã. Então, não faz sentido que ele tenha se aproximado do local em que ostensivamente se encontravam guardas municipais (giroflex ligado) apenas para ver o que estava acontecendo. Em verdade, restou demonstrado que ele se apresentou porque estava traficando junto com Carlos e este era seu amigo.

Outra incompatibilidade a demonstrar versão mentirosa. Em sede policial (fls. 09), Antônio declarou que estava trabalhando para Carlos como "olheiro" e que dividiam os ganhos com a venda de drogas. Em juízo, afirmou que assinou um papel sem ler e sua mãe estava presente na delegacia quando se negou a dar seu depoimento. Mais uma vez, o acusado deixou de fazer prova quanto a esse fato, que poderia ser facilmente corroborada por sua genitora. Ainda, há de se ressaltar que em audiência de custódia, o réu declarou que prestou depoimento, embora não ratificasse todo seu teor. Assim, percebe-se que, somente agora, meses após a prisão, Antônio alega que se negou a prestar depoimento em solo policial, sem qualquer prova que o respalde. Os confrontos também são nítidos nos depoimentos de Carlos.

Em juízo, Carlos declarou que não sabia que a região em que se encontrava é conhecida como ponto de venda de drogas, apesar de já ter sido preso por tráfico, o que descredibiliza sua declaração.

Continuando. Declarou que o valor encontrado em seu poder (R\$ 40,00) era seu e na época estava trabalhando todos os dias. Entretanto, no dia de sua audiência de custódia, alegou que estava desempregado há um mês. Logo, conclui-se que a quantia encontrada era proveniente da mercancia.

Mais. Carlos afirmou que estava no local para encontrar uma garota e que esta, inclusive, chegou a se apresentar aos guardas municipais para confirmar a versão de que teriam um encontro amoroso naquela noite, porém, referida pessoa não veio em juízo confirmar tal narrativa.

Por fim, o réu Carlos afirmou, quando ouvido em audiência de custódia, que estava

na companhia de Antônio quando foram presos. Disse que passou pela cerca, abaixou e então foi abordado pelos guardas. Por sua vez, Antônio declarou que nem conhecia Carlos antes de serem presos.

Pois bem. Diferentemente dos depoimentos dos guardas, as versões dos acusados são confusas, conflitantes entre si e nitidamente inverossímeis.

Por outro lado, sabe-se que a audiência de custódia se presta a verificação da integridade física dos presos e denúncia de possíveis maus tratos sofridos no momento da abordagem e prisão. Todavia, não há como se desconsiderar quando, espontaneamente e sem qualquer provocação, os presos acabam por relatar, ainda que superficialmente, os fatos ocorridos.

Esta é a situação concreta desses autos. As versões apresentadas pelos réus em juízo, quando de seus interrogatórios, encontram-se em total dissonância das por eles mesmos apresentadas em sede de audiência de custódia.

Isto evidencia, para além de qualquer dúvida, de que em juízo, deliberadamente mentiram para evitar a responsabilidade penal. Tentaram, em vão, desvincular-se um do outro, chegando a dizer que nem se conheciam, porém cometeram ato falho, uma vez que já haviam verbalizado que eram amigos.

No mais, em que pese não ser comum que algum acusado se apresente espontaneamente para ser preso, como foi o caso de Antônio, que sequer havia sido avistado pelos guardas, não se pode considerar tal conduta como impossível, sendo apenas improvável.

Não bastasse, a traficância restou comprovada pelas circunstâncias da apreensão do entorpecente (porções embaladas individualmente), sua quantidade, sua qualidade e diversidade ("crack" e cocaína).

Assim, sopesando-se todas as inconsistências apresentadas pelos réus e a higidez dos depoimentos dos guardas municipais, verifico que não restam dúvidas de que os réus traficavam drogas na data dos fatos, sendo que Carlos estava com o entorpecente nas mãos e Antônio o auxiliava como "olheiro".

Todavia, constato que houve mero concurso de agentes, uma vez que não ficou comprovada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, razão pela qual, quanto a este delito, devem os acusados ser absolvidos, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Por fim, não há que se falar, portanto, em porte para consumo pessoal, conforme pretende a Defesa dos réus, em razão da fundamentação acima exposta.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

- Do réu Carlos:

Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, cabe a análise pormenorizada de todas as circunstâncias judiciais que envolvem a infração penal. Sobre o assunto, vale ressaltar a importante lição do Desembargador Guilherme de Souza Nucci: "tem sido hábito de vários juizes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionado oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante. Demonstrando sua contrariedade a esse método e cuidando da reprovação social prevista no art. 59 do Código Penal, manifesta-se Luiz Antônio Guimarães Marrey, nos seguintes termos: 'Esse juízo de reprovação tem por base a conduta realizada pelo agente, cabendo ao juiz ponderar, na aplicação da pena, 'a forma e o modo de execução da ação descuidada, em face das exigências concretas de cuidado', para estabelecer a 'gradação material do perigo'. Justifica-se, portanto, o aumento da pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias em que

delinuiu, quando menos para não assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não apresentassem uma gravidade específica, peculiar e inconfundível com modestas vulnerações à ordem pública. A lei procura, claramente, separar o joio do trigo, recomendando o aumento da pena de modo proporcional aos efeitos da conduta, tanto mais quando sempre manda ter em conta, na primeira fase do cálculo, as 'consequências' do crime (CP, art. 59).

Logicamente, a maior extensão das penas deve repercutir na dimensão das penas, forçando a elevação do castigo. A despeito disso, há anos generalizou-se no foro o hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito. Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima. Não se sabe bem o que leva Magistrados tão diferentes, das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos, para puni-los, quase invariavelmente, no mesmo patamar, como se não apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível. Decididamente, não é por falta, na lei, de parâmetros adequados.

Tome-se o delito de roubo, para análise: na figura fundamental, dispõe o julgador de generosa escala (4 a 10 anos de reclusão), para acomodar os diversos episódios delituosos. Apesar disso, pouco importando as circunstâncias e consequências do delito, a culpabilidade revelada pelo autor, a conduta social deste e os motivos de sua prática, quase sempre se pune o assaltante, na base, com o quatriênio, como se todos aqueles fatores pudessem ser desconsiderados na composição da reprimenda. Com a indiscriminada imposição das penas mínimas, vem-se tratando de modo igual situações completamente distintas, de sorte a que, na prática, não se notem diferenças sensíveis na punição, que é a mesma ou quase a mesma, tenha sido o roubo cometido sob impulso momentâneo, figurando como objeto de escasso valor, com subjugação de uma única vítima, sem requintes de perversidade, ou decorra, ao contrário, de um premeditado projeto, lentamente acalentado, com intimidação de diversas pessoas, para obtenção de lucro fácil, destinado a sustentar o ócio de profissionais da malandragem. Essa tendência encerra, em verdade, dupla injustiça.

A mais evidente é com a própria sociedade, pois, devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito subalterno os critérios legais de fixação da pena, preordenados a torná-la 'necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime' (Código Penal, art. 59, caput)' (Protocolado 15.553/00, art. 28 do CPP. Inq. 222/97, Comarca de Guarulhos, 01.03.2000, grifo nosso)" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 13ª Edição, Editora Revista dos Tribunais).

Diante da análise do caso concreto, verifico que as circunstâncias judiciais extrapolam o normal para o tipo, eis que a conduta do réu merece maior reprovabilidade em virtude da natureza do entorpecente. Como é sabido, o "crack" possui especial potencial lesivo, vez que uma pequena dose pode ser letal, conforme apontam estudos médicos. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda quanto à primeira fase da pena, consigno que não há informações nos autos acerca da condenação de fls. 182/183 já ter transitado em julgado, motivo pelo qual não se presta para ser considerada como Maus Antecedentes.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, verifico que o acusado preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa, portanto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), ficando, por isso, fixada em definitivo, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial deve ser o aberto nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Em razão da gravidade dos fatos, entendo não ser cabível o benefício previsto nos artigos 43 e 44 do Código Penal.

Contudo, reputo presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, e entendo possível a concessão da suspensão condicional da pena. Dessa forma, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições: 1- proibição de frequentar casas de jogos, casas

noturnas e bares; 2- não se embriagar; 3- proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de dez dias sem autorização do Juízo; 4- comparecimento pessoal e obrigatório bimestral em Juízo para justificar suas atividades e 5- não tornar a delinquir.

Por aplicação do artigo 78, § 1º, do Código Penal, fixo, ainda, como condição, a prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade, em instituição a ser indicada pelo Juízo das execuções penais.

- Do réu Antônio:

Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, cabe a análise pormenorizada de todas as circunstâncias judiciais que envolvem a infração penal. Sobre o assunto, vale ressaltar a importante lição do Desembargador Guilherme de Souza Nucci: "tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionado oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante. Demonstrando sua contrariedade a esse método e cuidando da reprovação social prevista no art. 59 do Código Penal, manifesta-se Luiz Antônio Guimarães Marrey, nos seguintes termos: 'Esse juízo de reprovação tem por base a conduta realizada pelo agente, cabendo ao juiz ponderar, na aplicação da pena, 'a forma e o modo de execução da ação descuidada, em face das exigências concretas de cuidado', para estabelecer a 'gradação material do perigo'. Justifica-se, portanto, o aumento da pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias em que delinuiu, quando menos para não assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não apresentassem uma gravidade específica, peculiar e inconfundível com modestas vulnerações à ordem pública. A lei procura, claramente, separar o joio do trigo, recomendando o aumento da pena de modo proporcional aos efeitos da conduta, tanto mais quando sempre manda ter em conta, na primeira fase do cálculo, as 'consequências' do crime (CP, art. 59). Logicamente, a maior extensão das penas deve repercutir na dimensão das penas, forçando a elevação do castigo. A despeito disso, há anos generalizou-se no foro o hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito. Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima. Não se sabe bem o que leva Magistrados tão diferentes, das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos, para puni-los, quase invariavelmente, no mesmo patamar, como se não apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível. Decididamente, não é por falta, na lei, de parâmetros adequados. Tome-se o delito de roubo, para análise: na figura fundamental, dispõe o julgador de generosa escala (4 a 10 anos de reclusão), para acomodar os diversos episódios delituosos. Apesar disso, pouco importando as circunstâncias e consequências do delito, a culpabilidade revelada pelo autor, a conduta social deste e os motivos de sua prática, quase sempre se pune o assaltante, na base, com o quatriênio, como se todos aqueles fatores pudessem ser desconsiderados na composição da reprimenda. Com a indiscriminada imposição das penas mínimas, vem-se tratando de modo igual situações completamente distintas, de sorte a que, na prática, não se notem diferenças sensíveis na punição, que é a mesma ou quase a mesma, tenha sido o roubo cometido sob impulso momentâneo, figurando como objeto de escasso valor, com subjugação de uma única vítima, sem requintes de perversidade, ou decorra, ao contrário, de um premeditado projeto, lentamente acalentado, com intimidação de diversas pessoas, para obtenção de lucro fácil, destinado a sustentar o ócio de profissionais da malandragem. Essa tendência encerra, em verdade, dupla injustiça. A mais evidente é com a própria sociedade, pois, devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito subalterno os critérios legais de fixação da pena, preordenados a torná-la

'necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime' (Código Penal, art. 59, caput)' (Protocolado 15.553/00, art. 28 do CPP. Inq. 222/97, Comarca de Guarulhos, 01.03.2000, grifo nosso)" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 13ª Edição, Editora Revista dos Tribunais).

Diante da análise do caso concreto, verifico que as circunstâncias judiciais extrapolam o normal para o tipo, eis que a conduta do réu merece maior reprovabilidade em virtude da natureza do entorpecente. Como é sabido, o "crack" possui especial potencial lesivo, vez que uma pequena dose pode ser letal, conforme apontam estudos médicos. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, verifico que incide a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a reprimenda a seu patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o acusado preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa, portanto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), ficando, por isso, fixada em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) dias de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial deve ser o aberto nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Em razão da gravidade dos fatos, entendo não ser cabível o benefício previsto nos artigos 43 e 44 do Código Penal.

Contudo, reputo presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, e entendo possível a concessão da suspensão condicional da pena. Dessa forma, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições: 1- proibição de frequentar casas de jogos, casas noturnas e bares; 2- não se embriagar; 3- proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de dez dias sem autorização do Juízo; 4- comparecimento pessoal e obrigatório bimestral em Juízo para justificar suas atividades e 5- não tornar a delinquir.

Por aplicação do artigo 78, § 1º, do Código Penal, fixo, ainda, como condição, a prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade, em instituição a ser indicada pelo Juízo das execuções penais.

Para ambos os réus, fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para:

a) CONDENAR CARLOS HENRIQUE DO CARMO (RG nº 58698262), por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, mediante as condições acima especificadas, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo previsto em lei.

b) CONDENAR ANTÔNIO HENRIQUE GOES GUIMARÃES (RG nº 55997440), por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, mediante as condições acima especificadas, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo previsto em lei.

c) ABSOLVER CARLOS HENRIQUE DO CARMO (RG nº 58698262) e ANTÔNIO HENRIQUE GOES GUIMARÃES (RG nº 55997440) quanto à imputação pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Observo que o réu Antônio já se encontra em liberdade. Logo, concedo-lhe o direito de assim permanecer.

Quanto ao acusado Carlos, ante a pena aplicada que não importa em cárcere, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro delito/processo se encontrar preso. Expeça-se, com a máxima brevidade, o competente alvará de soltura

clausulado do réu.

Com fulcro no artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens encontrados em poder dos réus, por serem produtos do crime, em favor da União. Reverso o valor dos bens apreendidos diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA